

1500761-08.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 15/3/2022, por volta das 16h10, trazia consigo, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500761-08.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500761-08.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 15/3/2022, por volta das 16h10, trazia consigo, para fins de tráfico, 111 (cento e onze) invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 42,7 g (lacre n. 0246229); 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína sob a forma de crack, com massa líquida de 10,9 g (lacre n. 0246231); 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 42,5 g (lacre n.

0246230); 1 (um) comprimido de ecstasy; e 7 (sete) frascos de lança-perfume, drogas de uso proscrito nos termos da Portaria n. 344/98 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acusado apresentou resposta às fls. 112/120. Sustenta a nulidade absoluta das provas obtidas pela atuação dos guardas municipais. No mérito requer a absolvição sumária.

A denúncia foi recebida à fl. 135, em 2/6/2022.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado (fls. 158/159).

Em debates, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para incluir a causa de aumento do art. 40, III, da lei de drogas; no mérito, reiterou os termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado. A defesa, suscitou nulidade em razão da diligência realizada pelos guardas municipais. No mérito, requer a desclassificação para a conduta do art. 28.

É o relatório.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10^a ed., p. 673).

Pela acusação, Bruno Neori, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento conjunto com duas viaturas (viatura 02 e 03 comum, e 05 canil); próximo à escola Tenente Marques, viaturas avistaram o acusado agachado próximo a um entulho, perto da Rua Cruzeiro; quando viu guarnição se levantou e passou a caminhar em direção a um bar; abordado por James; equipe do depoente ficou na retaguarda; solicitado cão para farejar; encontrou drogas nas proximidades; com o réu R\$ 40,00 e porção de crack; 111 porções de cocaína, 5 de maconha, 1 de ecstasy, 7 de LSD e 33 de crack; prisão a cerca de 30/40 metros da escola; quem fez revista pessoal foi James (que estava na primeira viatura); acusado agachado no entulho manipulando sacola; foi questionado sobre venda e disse que seria usuário; local conhecido como ponto de vendas; solicitado o cão farejador porque mais rápido e preciso [na localização]; não visualizou réu com sacola na mão ou efetuando vendas; a princípio apenas acusado no local dos fatos; não conhecido dos meios policiais.

José Melo narrou que estavam em deslocamento, depararam com réu agachado próximo ao local; encontrada uma pedra de crack e R\$ 40,00 com ele; pegaram cão do canil e realizaram trabalho de faro próximo ao local, encontrando sacola de entorpecentes; não se lembra da variedade das drogas; não se recorda de ter abordado acusado anteriormente; não o viu com entorpecentes nem colocando em algum local na rua; cão farejador solicitado "pra tirar dúvida"; "bem mais prático"; no momento da abordagem não sabia onde estava a droga; local abordagem/porções: 10/15 metros.

O réu nega a traficância. Expõe que estava comprando pedra de crack; "enquadrado" perto do bar (havia entrado para usar banheiro); "pedra" encontrada em seu bolso; trabalha com reciclagem; tinha algumas pessoas no local; comprou "muito antes" da chegada da polícia; comprou crack cerca de 1 (uma) hora antes; não conhecia policiais.

No caso, apesar de ter alegado que trazia consigo apenas 1 (uma) porção de crack, destinada a consumo, as demais porções foram apreendidas nas imediações de onde estava, em quantidade incompatível com tal finalidade, presumindo-se que lhe pertenciam, especialmente em razão de sua reação ao notar a presença da guarnição. Não se ignora a existência de precedentes do TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quanto da fragibilidade da prova acusatória: "TRÁFICO DE DROGAS.

Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1^a Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1^a Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021)" - grifou-se.

Todavia, além de preso em flagrante ao lado das porções, individualizadas e variadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos com as declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "[...]; Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Sobre a preliminar relacionada à nulidade da diligência por se tratarem de guardas municipais, não prospera. A justa causa justificadora da abordagem foi manifestada pelos agentes em ambas as fases, qual seja, ao ser avistado manipulando objeto e se deparar com a guarnição, levantou-se e passou a caminhar em direção ao bar.

Neste norte: "REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pretensão do reconhecimento de nulidade do flagrante efetivado por guardas civis municipais e, por consequência, da absolvição - Impossibilidade - Justa causa para abordagem evidenciada nos autos - Não incidência das hipóteses previstas no artigo 621, inciso I, do CPP - Pedido indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 2254467-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)".

No mais, a situação de flagrância legitima a atuação de qualquer pessoa, nos termos do art. 301 do CPP: "1. Tráfico - Apreensão de drogas por guardas municipais - Flagrante puro e simples - Incidência do art. 301 do CPP - Nulidade - Não ocorrência - Suficiência probatória - Condenação mantida. 2. Penas - Básicas já fixadas nos pisos legais. 3. Redutor - Ampliação do desconto ao máximo - Pouca quantidade de tóxicos no peso total - Art. 42 da Lei 11.343/06. 4. Regime aberto - Possibilidade - Súmulas 440 do STJ e 718 do STF. 5. Substituição - Cabimento - Resolução 05/2012 do Senado Federal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501867-39.2019.8.26.0599; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Mor - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)".

Em conclusão, reputa-se materializado o crime de tráfico de drogas pelo auto de prisão em flagrante e demais documentos produzidos em sede policial (fls. 1/27), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 99/101, 103/105 e 109/111), e prova oral.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado, nos termos anteriormente ponderados, que dão conta da existência do dolo de traficância, reforçado pelo depoimento dos agentes públicos, coerente em ambas as fases, e pela vasta quantidade de drogas apreendidas, dissonantes da finalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, impondo-se a condenação.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com drogas de 5 (cinco) tipos distintos (cocaína, maconha, crack, ecstasy e LSD), a justificar o acréscimo de 1/6 em razão da natureza distinta das drogas.

Sobre a personalidade e conduta social do acusado, nada há nos autos que represente desabono, consignando que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

As demais circunstâncias judiciais não excedem a gravidade abstrata da figura típica, fixando-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nada a deliberar na segunda fase.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois o delito foi praticado nas imediações da escola Tenente Marques (30/40 metros, segundo a testemunha Bruno). Segundo o STJ: "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 10/8/2018)".

Desta forma, aumenta-se a pena da sexta parte, ajustada para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Diante da tese fixada pelo STJ no REsp 1.977.027, segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006", de aplicação obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, deve o acusado ser contemplado pela benesse legal, para diminuir a pena em 2/3, definitivamente fixada em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento é aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP), com possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação; b) prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Consigna-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e § 2º, do CP).

O valor unitário do dia-multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ANTONIO CARLOS PINHEIRO pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a manutenção da prisão preventiva, determina-se a imediata expedição de alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Cajamar, 2 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA